

1502209-91.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... transitada em julgado conforme certidão de fls. 43/44, por tráfico ilícito de entorpecentes (autos n. 0090149-72.2012.8.26.0050, que tramitou perante a 9ª Vara Criminal deste Foro Central), que será aqui considerada como maus antecedentes. Neste ponto, não que se falar em desconsideração da condenação acima apontada apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1502209-91.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502209-91.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FILIPPE PINHEIRO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

FILIPPE PINHEIRO DA SILVA e GABRIEL LUIZ SANTOS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §1º e § 4º, incisos I, II e IV, combinado com art. 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, segundo apurado, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 03h36min, na Rua Mohamad Ibrahim Saleh, nº 769, Cidade Nova São Miguel, São Paulo/SP, previamente acertados e conluiados entre si e com mais dois indivíduos não identificados, tentaram subtrair para proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo e escalada, coisas alheias móveis consistentes em cabos de energia elétrica, pertencentes à Associação de Pais e Mestres do CEI Jardim São Vicente, representada por F.R.F., somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia foi recebida, os réus foram citados e notificados e apresentaram resposta à acusação em audiência.

Os laudos periciais foram juntados à fls. 133/140 e 141/143.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, não sendo o caso de acordo de não persecução penal ou de suspensão condicional do processo, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos o representante da vítima, dois policiais e os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa pugnou pela improcedência da ação penal, requerendo a

absolvição dos réus com fulcro no art. 386, incisos II ou III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da desistência voluntária; a fixação da pena base no mínimo legal; o afastamento da qualificadora referente à escalada; o reconhecimento da atenuante da menoridade penal em relação ao réu Gabriel, bem como da confissão espontânea em relação a ambos réus; o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal; o reconhecimento da tentativa; a não aplicação da majorante referente ao repouso noturno, sob o fundamento de que o local onde os fatos se deram não é destinado a habitação; e a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena. É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição dos acusados à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

Por primeiro, não há que se cogitar a atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância. Isso porque, o princípio da insignificância se trata de uma construção jurisprudencial que deve ser aceita com ressalvas, sob pena de se cancelar judicialmente a impunidade que assola nosso país.

Como bem definiu o Ministro Celso de Mello, em acórdão paradigma sobre a matéria (HC 84.412-0/SP), o princípio da insignificância só deve ser reconhecido quando presentes simultaneamente quatro vetores: 1) a mínima ofensividade da conduta do agente; 2) a nenhuma periculosidade social da ação; 3) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e; 4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso vertente, a lesão se revelou significativa, em especial, em razão da característica dos bens furtados, visto que a subtração de cabos de energia elétrica de uma escola pública municipal comporta maior desvalorização jurídica e social em razão dos efetivos danos que a conduta pode provocar na continuidade da prestação do serviço público de ensino, não podendo assim a conduta ser considerada como insignificante para o mundo penal.

Ademais, deve-se levar em consideração que os réus praticaram o furto em questão em período de repouso noturno, por meio de escalada e rompimento de obstáculo e, ainda, em concurso de agentes, o que confere maior reprovabilidade à conduta dos agentes e afasta a aplicação do princípio da insignificância. Não é diverso o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRIVILÉGIO. ART. 155, §§ 2º E 4º, CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO HC. 1. A questão de direito tratada neste writ, consoante a tese exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da conduta realizada pelo paciente com base na teoria da insignificância, o que deverá conduzir à absolvição por falta de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico tutelado na norma penal. 2. O fato insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de tipicidade penal, podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em outras áreas do Direito, como ilícito civil ou falta administrativa. 3. Não considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º). 4. A lesão se revelou significativa não apenas em razão do valor do bem subtraído, mas principalmente em virtude do concurso de três pessoas para a prática do crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com a conclusão objetiva do caso concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do agente, sendo reprovável o comportamento do paciente. 5. Compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4º) e o privilégio (CP, art. 155, § 2º), desde que não haja imposição apenas da pena de multa ao paciente. 6. Habeas corpus denegado. Concessão da ordem de ofício por outro fundamento" (HC 94765, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008, DJe-182 DIVULG 25-09-2008 PUBLIC 26-09-2008 EMENT VOL-02334-03 PP-00575).

De outra banda, ao contrário do alegado, não há que se falar em comprometimento da materialidade do crime apenas e tão somente porque não há nos autos a avaliação dos bens. Basta que a ação do réu seja apta para diminuir o patrimônio da vítima para que o crime de furto se configure. No caso em tela restou claro que a ação dos causados era apta a causar prejuízo patrimonial a referida associação de pais e mestres.

Sendo que a materialidade do delito veio devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão do alicate encontrado na posse de um dos agentes, (fls. 27), pelos laudos periciais acostados aos autos (fls. 133/140 e 141/143), tudo aliado a firme e segura prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é inconteste.

Os dois réus nas duas oportunidades em que foram ouvidos (fls. 11 e 12) e em sede policial, confessaram os fatos narrados na denúncia.

O réu Filipe confessou que praticou a conduta com o objetivo de conseguir dinheiro para comprar drogas. Afirmou que juntamente com outros três indivíduos entraram na escola, sendo que um de seus comparsas escalou o poste para cortar os fios elétricos e rompeu o cadeado que trancava o portão do local e assim todos conseguiram ingressar no estabelecimento educacional.

Esclareceu que fios foram cortados, mas não foram retirados do local, pois ficaram presos na estrutura e que ao ouvirem um barulho de pessoas se aproximando do portão da escola, fugiram do local, sem nada conseguirem subtrair e que caminhava na via pública e foi abordado e preso pela polícia, confirmou, ainda que durante a ação acabou cortando um de seus pés.

No mesmo sentido, o réu Gabriel, em seu interrogatório judicial, confessou que na data dos fatos ele e mais três comparsas ingressaram na escola com o objetivo de subtrair os cabos de energia elétrica. Disse que tentaram retirar os cabos do local, mas não conseguiram e fugiram do local, porque ouviram o barulho de populares se aproximando. Durante a fuga, acabou sendo preso pela polícia.

A confissão de ambos os acusados, ao contrário do alegado pela Defesa, veio confirmada pelas outras declarações das testemunhas ouvidas em sob o crivo do contraditório.

Fabio Ricardo Fernandes, representante da associação vítima, ao ser ouvida em juízo declarou que é diretor da escola onde houve a tentativa de furto e que recebeu a informação de uma funcionária da escola de que houve uma tentativa de fios elétricos no local e que duas pessoas acabaram sendo presas.

Em razão disso, foi à escola e ali encontrou com os policiais e os dois réus já presos e tomou conhecimento do ocorrido.

Segundo os policiais populares que estavam no ponto de ônibus que fica bem próximo a escola, presenciaram o momento em que os indivíduos pularam o muro da escola e acionaram a viatura que fazia patrulhamento ostensivo pelas redondezas. Segundo os policiais, um dos agentes foi abordado em uma avenida próxima ao estabelecimento de ensino e o outro foi abordado nas redondezas trazendo consigo um carrinho de mão, dentro do qual foi encontrado um alicate.

Entrou na escola e pode observar que os furtadores estouraram a caixa de energia para ter acesso aos fios e, também, cortaram os cabos elétricos do poste que é conectado à caixa de energia e que o cadeado do portão de entrada do colégio e o que dava acesso ao local onde fica a caixa de energia estava rompido. Por fim, acrescentou que nada do interior da escola foi subtraído.

No mesmo sentido, após o compromisso de dizer a verdade, Guilherme Santos Araujo, policial militar, narrou que na data dos fatos estavam em patrulhamento pela via pública, juntamente com seu parceiro de farda momento em que avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença da viatura policial, saiu correndo. Diante da atitude suspeita, resolveram abordá-lo. Ao ser indagado sobre a atitude, o réu Gabriel informou que estava com medo, pois não queria ser preso novamente e acabou confessando à equipe policial que teria tentando furtar cabos de energia elétrica de uma escola próxima ao local da abordagem.

O réu relatou que estava na companhia de mais três ou quatro indivíduos e que não lograram êxito no furto, pois não conseguiram retirar fios do local. Diante de tais

informações, passaram a patrulhar as redondezas com o objetivo de localizar os demais agente do furto.

Foram ainda informados por populares, que se encontravam em um ponto de ônibus próximo ao local, que alguns indivíduos que tinham invadido a escola fugiram após avistar a viatura, sendo que um deles levava consigo um carrinho de mercado. Logo após, localizaram o réu Filipe carregando empurrando o carrinho e por isso resolveram abordá-lo. Durante a busca pessoal, localizaram um alicate de corte. Indagado sobre os fatos, o réu Filipe confessou que utilizou o alicate para cortar o cadeado da escola e os cabos de energia do local e que na tentativa de furto acabou machucando o pé. No mais, esclareceu que os réus cortaram um cadeado para ter acesso à escola e escalaram o muro do local para cortar os cabos de energia localizados no poste, que tem cerca de 2,5 metros a 3 metros. Informou que o furto ocorreu de madrugada, próximo às 4h ou 5h da manhã e que os populares que informaram o paradeiro dos furtadores foram convidados para seguir à delegacia como testemunhas do fato, mas nenhum se dispôs a fazê-lo. Por fim, declarou que não foi localizado com os réus nenhum bem de propriedade da escola e que nenhum objeto foi apreendido no local dos fatos e que a escola estava com manchas de sangue no chão. No mesmo sentido, Jonata Vinicius Ribeiro Silva Santos, policial militar, ouvido em juízo, confirmou a versão apresentada por seu companheiro de farda. Narrou que na data dos fatos estavam em patrulhamento, quando um indivíduo tentou empreender fuga ao se deparar com a viatura policial. Abordaram o indivíduo, que confessou que havia tentado furtar uma escola próxima ao local. Dirigiram-se ao local dos fatos, onde foram informados por populares que se encontravam em um ponto de ônibus que mais indivíduos teriam participado da ação criminosa e puderam observar que o chão da escola estava manchado de sangue. Poucos metros do local, abordaram um indivíduo que levava consigo um carrinho de supermercado e um alicate de corte e, que estava com um corte profundo em um dos pés e ao ser indagado, confessou que participou do furto à escola. No mais, declarou que os réus cortaram os fios da caixa de energia da escola e do poste que fica próximo ao local, além do cadeado do portão de acesso. Contudo, nenhum bem da escola foi localizado sob posse deles.

Ora, diante das provas colhidas não obstante os argumentos da douta defensora, de rigor a condenação dos réus.

É de asseverar, ainda, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos. Não é suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de agentes policiais. Ressalte-se que a diligência policial promovida neste processo decorreu tão somente do patrulhamento que realizavam pela região sem que haja qualquer indício que qualquer perseguição pelos policiais houvesse em relação aos acusados, ao contrário, ambos confessaram os fatos em versões quase que idênticas as prestadas pelos policiais, o que só reforça o posicionamento desta magistrada.

Nesse sentido, confira-se: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94)

Também não se pode olvidar que a prova suficiente à condenação por furto não é

daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento. Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação. A qualificadora referente ao concurso de pessoas restou provada tanto pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, bem como pela confissão dos réus, que afirmaram que agiram em conjunto, com outros indivíduos não identificados que conseguiram fugir.

Também presentes nos autos as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo.

Os dois réus confirmaram que o acesso a escola se deu pelo rompimento do cadeado que fechava o portão de acesso e que escalaram seu muro como objetivo de cortar os cabos elétricos do poste de energia.

Esses relatos vieram devidamente comprovados pelo laudo pericial do local dos fatos em que se constatou que "o ingresso na área externa ocorreu através de arrombamento do cadeado que guarnecia o portão mediante empenho de uso de ferramenta desconhecida e esforço físico" e, ainda, que "foram constatados danos na fiação do poste de energia pelo corte dos fios através de ferramenta de corte. Para acessar o poste foi constatado marcas de escaladas no muro externo com aproximadamente 4 metros", conforme relatório e fotografias constantes à fls. 133/140.

Por fim claro ainda nos autos que o crime ocorreu na madrugada e portanto, em repouso noturno e neste ponto, não há que se falar em afastamento do repouso noturno apenas em razão da posição topográfica do § 1º, do art. 155, do Código Penal.

De fato, não se desconhece que há decisões baseadas na mera argumentação de que, por uma questão topográfica, não caberia aplicar preceito antecedente ao subsequente e que a maior gravidade da figura qualificada e da pena a ela cominada já abrangeria as hipóteses descritas nas majorantes.

Com o tempo, contudo, começou-se a perceber que essa não era a melhor interpretação e que o legislador brasileiro não se ateve a tal critério (o topográfico), quando da elaboração das leis.

Tal entendimento começou, então a mudar notadamente no que diz respeito aos crimes de homicídio e furto, nos quais já se pacificou que a simples posição topográfica dos parágrafos em nada impediria a figura do crime "qualificado- privilegiado", ou mesmo o reconhecimento da figura do "repouso noturno" aos delitos de furtos qualificados.

A doutrina então começou a analisar tais decisões e passou-se a considerar nestes casos que "a posição da causa de aumento no tipo penal, bem como da qualificadora, é completamente indiferente, levando-se em conta o processo trifásico de aplicação da pena.

Em seu voto no HC 306.450-SP, a ministra Maria Thereza de Assis Moura destacou: Destarte, nessa linha de raciocínio, não haveria justificativa plausível para se aplicar o § 2.º do art. 155 do CP e deixar de impor o § 1.º do referido artigo, que, a propósito, compatibiliza-se com as qualificadoras previstas no § 4.º do dispositivo. Ademais, cumpre salientar que o § 1.º do art. 155 do CP refere-se à causa de aumento, tendo aplicação apenas na terceira fase da dosimetria, o que não revela qualquer prejuízo na realização da dosimetria da pena com arrimo no método trifásico.

Por outro lado, registra-se que não se desconhece o entendimento da Quinta Turma desta Corte segundo o qual somente será cabível aplicação da mencionada causa de aumento, quando o crime for perpetrado na sua forma simples (caput). Todavia, o fato é que, após o entendimento exarado em 2011 no julgamento do EREsp 842.425/RS, no qual se evidenciou a possibilidade de aplicação do privilégio (§ 2.º) no furto qualificado, não há razoabilidade em negar a incidência da causa de aumento (delito cometido durante o repouso noturno) na mesma situação em que presente a forma qualificada do crime de furto.

Em outras palavras, uma vez que não mais se observa a ordem dos parágrafos para a aplicação da causa de diminuição (§ 2.º), também não se considera tal ordem para imposição da causa de aumento (§ 1.º).

Em assim sendo, tendo em vista que o furto em tela é qualificado pelo concurso de

agentes e rompimento de obstáculos, não há qualquer óbice para aplicação da causa de aumento de pena (art. 155, § 1º, do Código Penal), devendo, portanto ser mantida.

Cumpra destacar julgado que fixa justamente essa orientação ao enfrentar hipótese análoga: PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. BEM AVALIADO EM R\$ 300,00. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA PRÁTICA DO DELITO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MIGRAÇÃO DA MAJORANTE PARA PENA-BASE. SOLUÇÃO MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. ... 3. A causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno – em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração –, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus...5. Ordem denegada. (Processo HC 424098 / SC – Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – SEXTA TURMA – Data do Julgamento 06/02/2018 – Data da Publicação/Fonte DJe 15/02/2018). No mesmo sentido e corroborando o entendimento ora esposado, o Supremo Tribunal Federal no HC 130952/MG, assim já se pronunciou "HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (CP, ART. 155, § 4º, I, C/C O ART. 14, II). CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (CP, ART. 155, § 1º) NAS FORMAS QUALIFICADAS DO CRIME DE FURTO (CP, ART. 155, § 4º).

ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E DE CONTRADIÇÃO LÓGICA QUE POSSA OBSTAR A CONVIVÊNCIA HARMÔNICA DOS DOIS INSTITUTOS QUANDO PERFEITAMENTE COMPATÍVEIS COM A SITUAÇÃO FÁTICA. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada. STF. 2ª Turma. HC 130952/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/12/2016 (Info 851).

Também não há que se falar em afastamento da referida causa de aumento de pena apenas porque se tratava de um estabelecimento escolar, local, portanto, não habitável.

Isso porque, embora não se desconheça posicionamento contrário, o legislador apenas se referiu ao momento em que o crime é praticado, ou seja, durante período em que é maior o perigo para o bem jurídico e se oferecem melhores oportunidades para a prática do delito, dada a maior carência de vigilância nas horas destinadas ao repouso da maioria, não havendo necessidade do lugar ser efetivamente habitado para a aplicação desta causa de aumento.

Neste sentido: TJSP: "Repouso Noturno- Da exegese do art. 155§1º, do CP, para a configuração da causa de aumento de pena, é de concluir que a lei não exige que o local seja habitado ou que se trate apenas de residência, ou ainda, que os moradores estejam ou não repousando- É suficiente que o crime seja cometido durante o horário de repouso noturno, momento em que há maior vulnerabilidade do o patrimônio alheio à ação dos criminosos" Ap.00926070.3/1-0000-000, j em 26-11-2007 -RT 870/605.

O furto, doutra parte, foi tentado já, conforme confessado em juízo, os réus e seus comparsas não conseguiram retirar do local os fios elétricos cortados, porque

pessoas que estavam na via pública se aproximaram do local o que fez com que eles fugissem .

Tais fatos, não obstante os argumentos trazidos pela Defesa, não configuram a desistência voluntária.

Neste sentido: "Desde que o agente pratique atos executivos objetivando o furto, dele desistindo por motivos alheios à sua vontade, caracteriza-se a tentativa, independentemente da apreensão da coisa furtiva" (STF – RCr. 92.332-2 GO- Rel. Min. Cunha Peixoto – 1ª T. – J 17.6.80- Un.)

Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena.

1) Réu FILIPE PINHEIRO DA SILVA

O réu é tecnicamente primário. No entanto, possui contra si condenação transitada em julgado conforme certidão de fls. 43/44, por tráfico ilícito de entorpecentes (autos n. 0090149-72.2012.8.26.0050, que tramitou perante a 9ª Vara Criminal deste Foro Central), que será aqui considerada como Maus Antecedentes.

Neste ponto, não se falar em desconsideração da condenação acima apontada apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, de fato, se por um lado ela não pode mais ser considerada como agravante em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de considerá-la como Maus Antecedentes, já que demonstra a personalidade criminosa do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

STJ- “condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de Maus Antecedentes” (HC456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, “não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência” (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos Veloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

“Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Além disso, considerando que o crime foi cometido mediante três qualificadoras, duas delas serão consideradas como circunstâncias judiciais, dada a contribuição para uma maior reprovabilidade da conduta. Assim, a pena base deve ser aumentada em 1/4, já que não lhe favorecem as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, chegando-se ao patamar de 02 anos e 06 meses de reclusão; e 12 dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena presente no caso a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j” e a atenuante da confissão e assim sendo a pena deve ser mantida no patamar acima estabelecido, já que tais circunstâncias se compensam. Apenas a título de fundamentação, respeitadas posições em contrário, embora a pena não tenha sido agravada pelos motivos acima expostos, ao contrário do sustentado pela douta Defesa, não é o caso de simplesmente se afastar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, já que o crime ocorreu durante o estado de calamidade pública da pandemia de Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879/2020), mormente no caso dos autos, pois em janeiro de 2022, estávamos frente a frente a uma nova variante que vinha provocando inúmeras mortes, o que causou, inclusive novo recrudescimento das restrições de mobilidade de todos.

É certo que a lei não prevê nenhuma condicionante finalística ou modal para que a agravante incida, sendo possível concluir que o legislador entendeu que o cometimento de delitos nas ocasiões excepcionais previstas demonstra o absoluto desprezo e insensibilidade do autor do fato à sociedade, já gravemente vulnerabilizada afetada em termos de saúde, economia, trabalho e perdas pessoais) pandemia e a seus valores, o que dota a conduta criminosa de um grau mais acentuado de reprovabilidade. Como aliás têm se posicionado nossos Tribunais superiores. Na terceira fase, é o caso de se reconhecer a ocorrência do furto noturno e assim a

pena deve ser aumentada em 1/3, chegando-se ao patamar de 3 anos, 4 meses de reclusão e 16 dias-multa.

De outra banda, verifica-se que o crime foi tentado, assim, considerando o iter criminis praticado pelos réus, que após romperem o cadeado e escalarem o muro, cortaram os os fios elétricos que apenas não foram subtraídos porque ficaram presos à estrutura do poste, e diante da aproximação de populares, a pena deve ser diminuída pela 1/3, e ser fixada em 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa.

2) Réu GABRIEL LUIZ SANTOS DA SILVA

O réu é primário e não possui antecedentes criminais atestado nos autos (fls. 45). No entanto, como o crime foi praticado mediante três qualificadoras (concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculos), duas delas serão aqui reconhecidas como circunstâncias do crime, conforme fundamentação acima esposada e a pena-base será então aumentada em 1/5, já que não lhe favorecem as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, chegando-se ao patamar de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão; e 12 dias-multa.

Na segunda fase há que se reconhecer a agravante decorrente da pandemia da COVID 19, pelos fundamentos acima esposados.

Também presente no caso em tela, menoridade do acusado, atestada nos autos e a confissão espontânea do réu, dessa forma, a pena deve retornar ao patamar mínimo legal estabelecido, de 02 anos de reclusão; 10 dias-multa, já que a pena não deve ser reduzida aquém do mínimo legal, nos termos do que prevê a súmula 231 do STJ. Na terceira fase, é o caso de se reconhecer a ocorrência do furto noturno e assim a pena deve ser aumentada em 1/3, chegando-se ao patamar de 02 anos e 08 meses de reclusão; e 13 dias-multa.

De outra banda, verifica-se que o crime foi tentado, assim, considerando o iter criminis praticado pelos réus, a pena deve ser diminuída em 1/3, chegando-se ao patamar de 01 ano, 09 meses e 10 dias, e 08 dias-multa.

Como não há nos autos provas da condição econômica dos acusados, fixa-se o dia multa no mínimo legal estabelecido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para o fim de condenar os réus como incurso no artigo 155, §1º e § 4º, incisos I, II e IV, combinado com art. 14, inciso II, todos do Código Penal, aplicando-se ao réu FILIPE PINHEIRO DA SILVA à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias, e 10 dias-multa no mínimo legal; e ao réu GABRIEL LUIZ SANTOS DA SILVA à pena de 01 ano e 09 meses e 10 de reclusão; e 08 dias-multa, no mínimo legal.

Considerando o montante da pena aplicada, a confissão e a primariedade dos réus, a substituição da pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direitos, que ficam ora estabelecidas por uma pena de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena substituída, e por outra pena de prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a ser destinada à entidade pública ou privada com destinação pessoal, que deverão ser determinadas no Juízo da Execução, sem o prejuízo do pagamento das diárias mínimas estabelecidas.

Em caso de descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO, notadamente em razão do montante de pena aplicada.

Considerando a pena aplicada, poderão os réus apelar em liberdade.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados, com urgência, em favor dos acusados.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Com a juntada do cálculo aos autos, abra-se vista às partes para ciência e eventual manifestação.

Comunique-se a vítima, consoante disposição legal.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA